

刑法
No70

H19-16

(配点: 2)

月	日
月	日

次のアからオまでの各記述について、判例の立場に従って検討し、甲に（ ）内の罪が成立するものは○、成立しないものは×とした場合、各記述と○・×の組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 甲は、乙にわいせつな行為をすることについての乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、乙が10歳であることを知りながら、乙に対してわいせつな行為を行った。(13歳未満の者に対する不同意わいせつ罪) (改)

イ. 甲は、乙を殺害することについての乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、乙の首をひもで絞めて殺害した。(同意殺人罪)

ウ. 甲は、乙の居宅に入ることに乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、乙が単身居住する乙の居宅に入った。(住居侵入罪)

エ. 甲は、乙に傷害を負わせることについての乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、過失による事故を装って保険金を詐取するため、甲の運転する自動車を乙に衝突させ、乙に傷害を負わせた。(傷害罪)

オ. 甲は、交通違反の取締りを受けた際に乙の氏名を名乗ることについての乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、交通違反を警察官に現認された際、乙の氏名を名乗り、交通反則切符の供述書に乙の名義で署名押印した。(有印私文書偽造罪)

1. ア○ イ× ウ× エ× オ×
2. ア× イ○ ウ× エ× オ○
3. ア○ イ○ ウ× エ○ オ○
4. ア○ イ○ ウ× エ× オ○
5. ア× イ× ウ○ エ○ オ×

No70	被害者の承諾と錯誤	正答率
H19-16	正 解	90%

ア 成立する

不同意わいせつ罪（176条3項）は、13歳未満の者が客体である場合、本人の同意があっても成立することから、13歳未満の者による同意は犯罪成立において意味がない。本事例において、甲が10歳の乙の承諾があると誤信していたことは何ら意味がなく、甲は、乙が10歳であることを知っており、甲に13歳未満の者に対する不同意わいせつ罪が成立する。

イ 成立する

名古屋地判平7.6.6は、「被告人は、被害者Aの囑託がないのにこれがあるものと誤信して殺害行為に及んだことが明らかであるから……囑託殺人罪の罪責を負う」と判示した。すなわち、被害者の真意に基づく同意はないのに、同意があるものと誤信して殺害した場合には、抽象的事実の錯誤として、殺人罪（199条）と同意殺人罪（202条）の構成要件が重なる範囲で軽い同意殺人罪が成立する。よって、甲には同意殺人罪が成立する。

ウ 成立しない

最判昭58.4.8（百選Ⅱ16事件）は、「刑法130条前段にいう『侵入シ』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解するべきである」として、承諾の不存在を構成要件該当事実であるとしている。したがって、本事例のように、乙の居宅に入ることについて乙の承諾がないのに、これがあると誤信して居宅に入った甲には、構成要件該当事実に関する事実の錯誤があり、故意が阻却されるから、住居侵入罪は成立しない。

エ 成立する

最決昭55.11.13（百選Ⅰ22事件）は、本記述と類似の事案において、「被害者が身体傷害を承諾したばあいには傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが、本件のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせたとばあいには、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではない」と判示した。したがって、甲に傷害罪（204条）が成立する。

オ 成立する

一般的に、名義人から名義の使用について承諾がある場合には、私文書偽造罪（159条）は成立しない。しかし、最決昭56.4.8（百選Ⅱ97事件）は、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、右供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する」と判示した。これは、交通事件原票中の供述書について、名義人の承諾の有無により私文書偽造罪の構成要件である「偽造」に当たるか否かは左右されないという趣旨である。よって、甲が名義人乙の承諾を得たと誤信しても、偽造という構成要件該当事実の認識に欠けるところはないから、故意は否定されず、甲に有印私文書偽造罪が成立する。